

1500168-39.2022.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... o réu trazia consigo, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, devidamente apreendidas (fls. 11/13) e constatadas (fls. 32/35)".

Nas circunstâncias acima descritas, DOUGLAS praticava atos relacionados ao narcotráfico, ao passo que trazia consigo, para fins de tráfico, ao todo, 42 pinos de cocaína (25.78g), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

1ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500168-39.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500168-39.2022.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2056233/2022 - DEL.POL.APARECIDA, 23285736 -

DEL.POL.APARECIDA, 2056233 - DEL.POL.APARECIDA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS ANTONIO SILVESTRE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

O Ministério Público denunciou DOUGLAS ANTONIO SILVESTRE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sob a alegação de que o réu, "no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 21h45, na Rua Itaiguara, nº 200, Itaguaçu, nesta cidade de Aparecida, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, devidamente apreendidas (fls. 11/13) e constatadas (fls. 32/35)".

Nas circunstâncias acima descritas, DOUGLAS praticava atos relacionados ao narcotráfico, ao passo que trazia consigo, para fins de tráfico, ao todo, 42 pinos de cocaína (25.78g), individualizados para a comercialização (fotografias às fls. 75/77, 79 e 85).

Ocorre que naquela ocasião, enquanto deixava o interior do imóvel situado no local dos fatos, caminhando em direção ao portão de entrada, DOUGLAS, deparando-se com a aproximação dos policiais Aguinaldo Porto da Silva e Anderson de Souza Bastos - que lá compareceram acompanhados de seu sobrinho adolescente Paulo Miquéias Silvestre Moreira, também residente no local, detido pelos policiais em poder de drogas e simulacros de arma de fogo, nervoso, correu em direção ao interior da casa e, após arremessar uma sacola plástica que trazia consigo por baixo de uma escada, dirigiu-se ao interior do banheiro.

Atendendo à ordem dos policiais, deixou referido cômodo e se posicionou na cozinha, instante em que de suas vestes caiu ao chão determinada substância em pó, de coloração branca. Ato contínuo, após breve tentativa de fuga, acabou detido pelos milicianos.

Em revista pessoal, os policiais apreenderam em seu poder o importe de R\$ 128,00, em espécie, além de 1 pino contendo cocaína. Em seguida, revistado o interior da sacola por ele dispensada, localizaram outros 41 pinos contendo a mesma droga. (fls. 150/152).

O réu foi preso em flagrante, com conversão da prisão em preventiva (fls. 128/132). A denúncia foi recebida em 17 de março de 2022.

O réu foi pessoalmente citado (fl. 190) e apresentou resposta à acusação às fls. 195/198, pugnando pela rejeição da denúncia e desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Alegações finais orais do Ministério Público pela procedência da ação nos termos da denúncia.

Alegações orais da Defesa sustentando a ausência de provas da autoria delitiva.

Subsidiariamente, pediu o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de drogas, com a fixação no seu redutor máximo.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fatos tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

A ação penal é PROCEDENTE, com efeito, analisando atentamente o acervo probatório, e considerando os elementos indiciários existentes nos autos, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, devendo ser o acusado condenado nos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Nestes termos, do percutiente exame do acervo probatório, infere-se que restaram satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

PRELIMINARMENTE

DO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO

Cumpra salientar que, a despeito das alegações do acusado de que os policiais teriam ingressado em sua residência sem autorização e sem mandado judicial, tal ingresso é válido e regular.

Vejamos.

O artigo 5º, XI, da Constituição de 1988, traz a proteção ao domicílio, tornando-o inviolável. Por domicílio, entende-se o espaço físico no qual o indivíduo goza de sua privacidade, nas suas mais variadas modalidades. Assim, o domicílio deverá ser entendido como qualquer compartimento habitado utilizada para moradia, profissão ou atividade. Por isso, escritórios, consultórios devem ser enquadrados no conceito de domicílio.

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Portanto, durante o dia, é possível o ingresso em domicílio nas seguintes

hipóteses: com o consentimento do morador, em caso de flagrante delito, desastre,

para prestar socorro, ou mediante determinação judicial. Durante a noite, o ingresso em domicílio alheio só pode ocorrer nos seguintes casos: com o consentimento do morador, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Como acima transcrito, uma das hipóteses em que é permitido o ingresso em domicílio alheio são nas situações de flagrante delito. Ora, dos autos consta, que em sua residência foram encontradas as substâncias entorpecentes apreendidas. O crime de tráfico de drogas é peculiar, pois algumas de suas condutas correspondem a crimes permanentes, cuja consumação se prolonga no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento.

Dessa forma, quem, por exemplo, guarda ou tem em depósito determinada quantidade de droga em sua residência está continuamente em flagrante delito.

Considerando a exceção trazida pelo próprio dispositivo constitucional a respeito da inviolabilidade do domicílio, conclui-se que o armazenamento de drogas em determinada residência admite a entrada de agentes policiais independentemente de autorização judicial.

No caso dos autos, haviam fundadas suspeitas de que no interior da residência do acusado estaria ocorrendo o flagrante delito. Em primeiro lugar, o adolescente Paulo Miqueias, abordado anteriormente na posse de drogas e de simulacros de arma de fogo, informou que na residência possuía uma arma de fogo, sem informar se seria ou não um mero simulacro.

Além disso, quando os policiais estavam na porta da residência, o acusado Douglas, que estava saindo da casa, ao avistar a viatura, correu para o interior da residência, com as duas mãos em sua cintura, conforme relatado pelos policiais. Tal conduta, como ficou claro do depoimento dos agentes da lei, incutiu neles a fundada suspeita de que Douglas estivesse portando arma de fogo, motivando sua perseguição para o interior da residência.

Tal situação, por si só, já dispensaria a prévia autorização judicial para ingresso no domicílio.

Dessa forma, observo, portanto, que a conduta está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal, formalizada no julgamento do RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual se firmou entendimento no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

Este é, inclusive, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

"Habeas corpus" - Tráfico de drogas - Alegação de que as provas foram obtidas ilicitamente, mediante violação de domicílio - Pedido de concessão de ordem para trancar a ação penal e nulificar o feito, com a consequente soltura do paciente - Não acolhimento - Ausência de constrangimento ilegal - Inteligência do art. 5º, XI, da CF, que dispensa consentimento do morador e ordem judicial para o ingresso em domicílio alheio nos casos de "flagrante delito" - Tráfico de drogas nas modalidades "guardar" e "ter em depósito" - Crime permanente - Possível a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP) - Existência de fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais na residência do paciente - Precedentes - Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2057567-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 08/04/2021; Data de Registro: 08/04/2021)

Assim posto, resta afastada qualquer nulidade da obtenção da prova.

DELITO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06

A materialidade do delito acha-se consubstanciada nos documentos produzidos em sede policial, notadamente auto de exibição e apreensão (fls. 11/13), laudos de constatação e de exame químico-toxicológico (fls. 220/222), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

A autoria resta igualmente demonstrado, especialmente pela ampla prova oral produzida em audiência, que definem, sem qualquer sombra de dúvida, a autoria delitiva do réu.

Passo a análise da prova oral produzida.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público, policial militar Aguinaldo Porto da Silva declarou em juízo que:

Que estava em patrulhamento de rotina pelo bairro do Itaguassu, na cidade Aparecida. Que nesse local, avistaram um indivíduo que demonstrava certo nervosismo. Que abordaram este indivíduo. Que com esse indivíduo encontraram uma pochete com 4 porções de maconha, além dois simulacros de arma de fogo. Que esse indivíduo abordado era sobrinho do acusado Douglas, chamado Paulo Miqueias, adolescente. Que o adolescente Paulo Miqueias narrou que em sua casa possuía mais uma arma. Que se dirigiram à residência do adolescente e, lá chegando, se depararam com o acusado Douglas, que estava saindo da casa. Que quando o acusado avistou a polícia, virou de costas, colocou as duas mãos na cintura e correu para interior da casa. Que em razão de tal conduta, ingressaram no imóvel em seu encalço. Que no momento da fuga viram o acusado arremessar uma sacola para debaixo da escada. Que o acusado se escondeu no banheiro. Que o acusado saiu do banheiro em direção a cozinha. Que nesse momento caiu um porção de drogas de suas. Que o acusado tentou se evadir do local, pela porta da residência. Que o acusado entrou em luta corporal com outro policial que estava na rua, fazendo a segurança. Que conseguiram deter o acusado e, em revista pessoal, com ele encontraram 128 reais em dinheiro e 1 pino de cocaína. Que debaixo da escada, encontraram a sacola dispensada pelo acusado Douglas, onde havia 41 pinos de cocaína. Que no quarto do adolescente Paulo Miqueias encontrou-se outro simulacro de arma de fogo.

Em resposta aos questionamentos levantados pelo Ministério Público, respondeu que: Que o pai do adolescente acompanhou a diligência. Que viu o acusado dispensando um objeto para debaixo da escada, local onde encontraram a sacola. Que o acusado confessou, de forma informal, o tráfico de drogas. Que o local onde feita a prisão do acusado, é conhecida por tráfico de drogas. Que já abordou o acusado algumas outras vezes no local, mas nunca encontrou nada de ilícito com ele.

Em resposta aos questionamentos levantados pela defesa, respondeu que:

Que não conhecia o Paulo Miqueias anteriormente. Que o adolescente foi abordado no bairro do Itaguassu. Que conheceu o adolescente somente no dia do fato. Que o próprio adolescente informou aos policiais o local da residência. Que o adolescente informou aos policiais que possuía um revólver em casa, mas não disse se era um simulacro. Que o adolescente nada disse a respeito das drogas em casa. Que a abordagem foi realizada no começo da noite, não se recordando do horário exato. Que o adolescente permaneceu na viatura. Que os fatos se deram de forma muito rápida. Que o pai do adolescente foi quem acompanhou toda a vistoria na residência. Que no local onde foi encontrada a sacola com os entorpecentes possuíam outros objetos. Que viu o acusado dispensando essa sacola, que foi a mesma onde encontraram os entorpecentes. Que o pai do adolescente autorizou a entrada e acompanhou as buscas. Que não sabe dizer quantas pessoas moravam no local. Que no local há duas residências, uma no térreo e uma no segundo pavimento. Que no local estavam presentes o acusado Douglas e o pai do menor. Que o portão da casa estava aberto e ingressaram em razão da conduta do acusado, que correu da viatura com as mãos na cintura. Que não encontrou arma de fogo em poder do acusado. Que o menor Paulo Miqueias informou que possuía uma outra arma na residência, mas não disse se seria um simulacro ou não. Que um outro simulacro de arma de fogo foi encontrado no guarda roupas no Paulo Miqueias. Que no quarto do Paulo Miqueias encontrou mais 10 dez eppendorf. Que no cômodo ocupado por Douglas não encontraram entorpecentes. Que a sacola foi encontrado no local onde o acusado a dispensou.

Que conseguiu efetivamente visualizar o objeto dispensado pelo acusado Douglas, que foi a sacola posteriormente encontrada com os entorpecentes no seu interior.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público policial militar Anderson de Souza Bastos narrou em audiência que:

Que estava em patrulhamento pela cidade de Aparecida, no bairro do Itaguassu. Que abordaram o menor Paulo Miqueias. Que com ele foi encontrado drogas e dois simulacros de arma de fogo em sua cintura. Que por conta de ser menor, se deslocaram com ele até o endereço de sua residência. Que chegando à residência do menor, viram que era na rua do escadão, local conhecida por tráfico. Que quando pararam na porta da casa, o acusado Douglas, que estava saindo da casa, viu a

viatura, retornou rapidamente para a residência, virando de costas, com as mãos na cintura. Que por conta disso, além do fato do menor ter dito que havia mais armas na casa, foram ao encalço do acusado Douglas. Que durante a fuga, o acusado dispensou uma sacola para debaixo de uma escada e se escondeu no banheiro da residência. Que o acusado tentou se evadir da casa, entrando em luta corporal com a equipe. Que o acusado foi detido e, em seu poder, encontraram uma porção de cocaína e 128 reais em dinheiro. Que retornaram a casa, ocasião que o pai do adolescente Paulo Miqueias autorizou a busca na casa. Que encontraram embaixo da escada, a sacola que foi dispensada pelo acusado, onde continha os entorpecentes.

Em resposta aos questionamentos levantados pelo Ministério Público, respondeu que: Que o menor Paulo Miqueias declinou que havia outra arma de fogo na casa, mas não disse seria um simulacro. Que o fato do acusado Douglas ter corrido com as mãos na cintura, sugeriu que estivesse armado, motivando sua perseguição. Que as buscas no local foram acompanhadas pelo pai do adolescente Miqueias. Que no local estava a mãe do adolescente Miqueias, e depois chegaram outras pessoas. Que já possuía denunciadas por tráfico de drogas com Douglas. Que o acusado foi abordado outras vezes, mas nada de ilícito encontrado, sendo liberado. Que o acusado confessou, de forma informal, o tráfico..

Em resposta aos questionamentos levantados pela defesa, respondeu que:

Que não conhecia o adolescente Paulo Miqueias anteriormente, que foi a primeira vez que o abordou. Que o adolescente não disse nada a respeito de drogas na casa, apenas informou a existência da arma ou simulacro de arma de fogo. Que entrou na residência junto com seu parceiro Aguinaldo, correndo no encalço do acusado. Que na diligência estavam três policiais. O outro policial era o motorista da viatura, que ficou responsável pelo adolescente Paulo Miqueias enquanto iam em direção ao acusado Douglas. Que quando chegou ao local, o acusado Douglas estava saindo da residência e, ao ver a viatura, correu para o interior da residência, com as mãos na cintura. Que ele e Aguinaldo foram ao seu encalço. Que o acusado, no momento que correu, dispensou a sacola embaixo da escada e se escondeu no banheiro da residência. Que quem localizou a sacola foi o Aguinaldo e que estava ao seu lado. Que abriu a sacola na hora, contando os 41 pinos de cocaína. Que era uma sacola plástica, não se lembra dos detalhes. Que era uma sacola plástica branca, mas não sabe se possuía alguma marca. Que embaixo da escada possuíam outros objetos. Que no local possuem duas residências, uma no térreo e uma no segundo pavimento. Que não foram ao segundo pavimento, em razão de ter sido informado que o quarto do menor ficava na parte de baixo do imóvel.

Interrogado, o réu DOUGLAS ANTÔNIO SILVESTRE alegou em juízo que:

Que não reside no local dos fatos, sendo ali residência de sua mãe. Que estava no local apenas visitando sua mãe. Que a policial invadiu a casa, e ele estava na varanda brincando com suas filhas. Que os policiais chegaram apontando a arma em sua direção. Que mandou que os policiais abaixassem a arma. Que iniciou uma discussão com os policiais. Que foi deitado por desacato. Que não possuía nenhuma droga com ele. Que foi seu próprio irmão quem deu a sacola com as drogas para os policiais. Que essas drogas não lhe pertenciam e que não sabe declinar sua procedência. Que é usuário de cocaína. Que não conhecia os policiais anteriormente e não sabe dizer algum motivo que eles teriam para incriminá-lo. Que a sacola foi seu irmão que entregou aos policiais. Que não sabe onde a sacola estava.

Cumprido salientar que, a despeito das alegações do acusado, os dois policiais militares, quando ouvidos em juízo sob compromisso de dizer a verdade, narraram, sem deixar qualquer dúvida e em total coesão e harmonia, que o réu Douglas Silvestre, ao avistar os policiais, tentou se evadir para o interior de sua residência, sendo preso no interior da residência. No mais, ambos os policiais narraram que, durante a tentativa de fuga, o acusado dispensou uma sacola plástica para baixo de uma escada. E que essa sacola plástica foi apreendida e nela encontrados os entorpecentes apreendidos e periciados. Os policiais afirmaram, em depoimento coeso e firme, que viram o acusado dispensando a sacola e que nessa sacola encontraram os entorpecentes.

No tocante à idoneidade de depoimentos de Policiais Militares, mister ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever

funcional, com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nos autos.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP – AC – Rel. Carlos Bueno – RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

“Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ – AC – Rel. Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

Nesta senda:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97, p. 12.189, in TACRIM - As mais recentes decisões nº 5, Jun/97, p.07

“Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ – AC – Rel. Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

Portanto, a prova trazida pelos policiais tem o condão de conduzir a condenação dos acusados, tendo em vista que os depoimentos são coesos, lógicos e sequenciais, além de trazerem detalhes a respeito dos fatos ora apurados. Ademais, não há que se falar em contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação, uma vez que não entraram em contradição em momento algum.

Além disso, é esse o entendimento dos Tribunais:

“Pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboçar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias nos pontos secundários que são frutos da imperfeição do psiquismo humano” (JUTACRIM, vol. 95/26, rel. Segurado Braz).

“O importante é como nos diz DELLAPIANE, verificar se embora descorando dos detalhes mínimos concorra a final nos pontos essenciais, nas circunstâncias mais importantes do fato que cada uma, isoladamente reconstituiu” (Nova Teoria da Prova – 2ª ed., Ed. Konfino, 1958 – pág. 145).

Ora, como se vê, a versão trazida pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados é lógica e coesa, não trazendo quaisquer elementos que a ponham em cheque. Assim, nada há que se discutir quanto à forma como se deram os fatos.

Ambas as testemunhas confirmaram, de modo coerente e lógico, confirmaram que o réu estava na posse das substâncias e materiais apreendidos.

Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na

conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice.

Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos, sobretudo as confissões espontâneas dos acusados em juízo.

A prova produzida nos autos é segura e conclusiva, sendo apta a autorizar o decreto condenatório.

Dá-se o crime de tráfico ilícito de drogas quando o agente pratica um dos núcleos do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Trata-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a realização de um único verbo do tipo para a adequação da conduta.

No caso dos autos, o réu trazia, guardava e tinha em depósito para a entrega ilícita ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes (cocaína) que causam dependência física e psíquica, para entrega a consumo de terceiro.

Analizados os aspectos referidos, que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, é evidente que a droga encontrada destinava-se ao tráfico, mormente pela quantidade encontrada, pelo local e circunstâncias da apreensão, bem como pela forma de acondicionamento, incompatível com o mero usuário.

Cabe citar que a venda propriamente dita da droga não é elemento indispensável para a configuração da traficância, tendo em vista consistir o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) em tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração do aludido delito, a prática de qualquer uma das 18 ações tipificadas (importar, exportar, remeter preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), dispensada a prova do ato da mercancia em si, perfilhando desse mesmo entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos. (STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJ e 01/07/2016)

Nesse sentido, a jurisprudência:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o intuito da traficância pode ser inferido pela quantidade, forma de acondicionamento da droga, comportamento do representado logo antes ou no momento da apreensão, a existência de outros elementos referentes à venda, etc.

Nesta senda:

"A natureza altamente lesiva e a quantidade de porções da droga capturada, somadas à apreensão de apetrechos geralmente utilizados no preparo e disseminação de tóxicos, bem como de certa quantia em dinheiro, são fatores que indicam envolvimento maior com a traficância, autorizando à preventiva." (HC 323.748/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, REPDJ e 05/10/2015, DJ e 28/09/2015).

Quanto ao destino das drogas apreendidas, não se discute que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao nefando tráfico. A natureza das drogas apreendidas, a maneira como estavam acondicionadas, bem como as condições de tempo e lugar em que os acusados foram abordados, além das declarações dos policiais, denunciam o referido comércio.

Portanto, o acusado realizou conduta típica, antijurídica e punível, em face de sua culpabilidade, impõem-se a condenação e a pena, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o acusado.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Logo, presentes todos elementos normativo do tipo penal inscrito no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, que faço com fulcro nos arts. 59 e 58, do CP.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, verifico que o acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes. Conforme se observa de sua certidão de antecedentes (fls. 95/99), bem como de sua folha de antecedentes (fls. 100/115), possui ele condenações definitivas já atingidas pelo período depurador. Embora tais condenações não possam ser consideradas para fins de reincidência, conforme prevê o art. 64, I, do Código Penal, nada impede que sejam valoradas à título de maus antecedentes, na primeira fase da dosagem da pena. As demais circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, bem como do art. 42, da lei 11.343/06 são normais à espécie de delito. Assim, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na fase intermediária, segundo sua folha de antecedentes (fls. 101/102), o acusado é reincidente específico no delito de tráfico de drogas (autos 0005629-17.2013.8.26.0028) atraindo a agravante prevista no art. 64, I, do CP.

Dessa forma, agravo a pena no patamar de 1/6, fixando a pena intermediária em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

Ainda na terceira e derradeira fase, ao contrário do que requer a combativa defesa, tendo em vista que o acusado é reincidente, inviável o reconhecimento do redutor de pena da figura privilegiada do tráfico. Os requisitos previstos no art. 33, §4º, quais sejam primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa são CUMULATIVOS, de modo que para o acusado fazer jus a tal causa de diminuição de pena, devem estar presente todos os requisitos, o que não é o caso do apenado.

Não estão presentes causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, torno-as de definitiva nesse montante.

Considerando que o réu é reincidente e que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP NÃO lhe são inteiramente favoráveis, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, com fulcro no artigo 33, §3º, do Código Penal. Os fatores elencados na primeira fase da dosimetria não permitem a submissão imediata do acusado a regime de menor vigilância afastando, assim, a incidência da Súmula nº 269 do STJ. Deixo de aplicar a detração para fins de fixação do regime prisional, haja vista que perfilhamos o entendimento de que a inovação legislativa ao ampliar o alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a detração já na sentença condenatória termina por confundir dois institutos penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena; confusão que viola os princípios de individualização penal, do juiz natural e da isonomia; todos de índole fundamental previstos no artigo 5º, caput, e incisos XLVI e LIII, da Constituição da República. O período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal.

Pelos mesmos motivos, inviável a substituição das penas por restritivas de direitos ou a concessão de qualquer outra benesse, tendo em vista que o réu é reincidente em crime doloso, e as circunstâncias do crime, bem como a personalidade do condenado indicam que a substituição não seria suficiente ao atingimento dos objetivos da pena. Sendo o réu reincidente, estando cumprindo pena privativa de liberdade por outro crime, inviável a concessão de Sursis ou da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ser socialmente recomendável e suficiente para a justa reprimenda.

O dia-multa, em face da ausência de dados quanto à situação econômica dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração. Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado DOUGLAS ANTÔNIO SILVESTRE, por ter praticado fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, no menor valor legal.

O condenado respondeu ao processo em custódia cautelar. Agora, confirmada a certeza de sua culpabilidade, e presentes os motivos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, seria um contrassenso e injustificável sua soltura, razão pela qual não poderão recorrer em liberdade, sendo de rigor a manutenção de sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, principalmente pelo fato do réu ser reincidente, e que estava em cumprimento de pena quando praticou o fato criminoso pelo qual está sendo sentenciado, circunstâncias essas que denotam alta probabilidade de que o condenado, em liberdade, se furtará à aplicação da lei penal.

Anote-se a publicação da presente sentença como termo inicial para eventual nova reapreciação da necessidade da prisão preventiva, devendo os presentes autos virem conclusos ao Magistrado com competência funcional sobre o processo (Juiz de Direito ou Desembargador Relator, a depender da fase em que se encontrar) no 85º dia a partir desta data, na forma do Comunicado n. 78/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Decreto ainda o perdimento da quantia em dinheiro apreendida em favor do FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Condeno o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão.

Após o trânsito em julgado:

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;

Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art.

336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Aparecida, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA